

0056990-31.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0056990-31.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0056990-31.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 5880/2018 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 872/2018 - 50º

Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABIANO BATISTA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

FABIANO BATISTA DE JESUS, R.G. 40.265.292, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isto porque no dia 26 de junho de 2018, em horário incerto, na Rua Francisco Cubas Ferreira, nº 521, Jardim Romano, nesta capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 33 trouxinhas de cocaína, 17 eppendorfs de cocaína e 17 trouxinhas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 335,65, em espécie, proveniente do comércio ilícito de entorpecentes.

Segundo apurado, policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o denunciado com uma pochete preta nas mãos. No instante em que o denunciado viu os policiais, empreendeu fuga e dispensou a pochete.

Contudo, os policiais lograram êxito em detê-lo e recuperar a pochete, que continha em seu interior as drogas e a quantia em dinheiro.

O laudo de constatação resultou positivo para 29,4 gramas de cocaína e 31,6 g de maconha, sendo certo que a quantidade de drogas e as circunstâncias da prisão demonstram que o denunciado se dedicava ao tráfico.

Lavrado o auto de prisão em flagrante (fls. 04), o acusado recebeu nota de culpa (fls. 08), foi qualificado e pregressado (fls. 25/28).

Oferecida a denúncia de fls. 01/02, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 03/37, foi ela recebida por despacho do dia 30 de julho de 2019 (fls. 133/134). Consequentemente, o acusado foi notificado (fls. 105), vindo aos autos, no prazo legal, defesa preliminar de fls. 129/132, subscrita pela Defensora Pública nomeado, tendo o acusado sido citado e intimado a fls. 151.

Durante a instrução da causa foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação e o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, sendo que o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, regime fechado.

A douta Defensora requereu a absolvição do acusado. Em caso de condenação, requereu a aplicação do privilégio na medida que é tecnicamente primário. Pena mínima, regime aberto e recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o auto de exibição e apreensão (fls. 13), o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 163/165), o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 10/12) e a folha de antecedentes criminais do acusado (fls. 89/94).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.13) e dos laudos de constatação provisória (fls. 15/16), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 163/165), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

O policial Bruno reconhece o réu desta ocorrência policial. O local é conhecido como sendo de tráfico de drogas. O local é no Jardim Romano. Havia denúncia s de tráfico no local. Avistou o acusado que tentou fugir. Correu para uma viela e na viela ele arremessou a pochete para cima de um telhado. Primeiro procurou deter o acusado e depois voltou ao local e conseguiu pegar a pochete. Dentro encontraram maconha, crack e cocaína e pouco mais de trezentos reais. O entorpecente estava embalado para a venda. O réu negou a propriedade do entorpecente. Viu o momento em que ele jogou a pochete no telhado e pode afirmar que o que foi apreendido era a mesma pochete. O réu declarou ser usuário.

O policial Lindenbergue também reconheceu o acusado da prática de tráfico de entorpecente do bairro jardim Romano, a noite. Ele já era conhecido por tráfico. O réu, ao ver os policiais, empreendeu fuga e tentou se livrar da pochete jogando-a em cima de uma casa. Continuaram na perseguição. Ele foi detido e com ele nada foi apreendido. Em seguida apreenderam a pochete. Dentro da bolsa, encontraram entorpecente variado, já embalado para venda e dinheiro, acima de R\$ 300,00. Ele negou que a pochete fosse dele. Não se recordou se ele disse o que estava fazendo no local. Ele tentou se evadir e entrar em um bar.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos

no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

Por fim, o acusado, em juízo, optou por ficar em silêncio, vejamos.

Fabiano, trabalha no farol e vende pano de chão. Mora com os irmãos. Tem 35 anos de idade. Não tem filhos. Quanto a condenação por trafico, quando caiu para 1 ano e 08 meses, já havia cumprido a pena.

Não restam duvidas, a meu ver a respeito da culpabilidade do acusado que estava no local dos fatos vendendo entorpecente. Não há elementos que comprovem que os policiais estavam no propósito de prejudicar o acusado.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, nada a considerar.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do trafico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é tecnicamente primário e embora ostente antecedentes, fls. 92, entendo que ele é merecedor do benefício porque desde 2018 não voltou a praticar crimes, está solto e não entendo adequado que ele retorne ao sistema carcerário. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa apenas porque estivesse na posse de entorpecente, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a mediana, ou seja, 1/2.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 1/2 (um meio), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 02 (dois anos) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a pratica delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno FABIANO BATISTA DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências

cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 13). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Recurso em liberdade.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de junho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA